

1500389-95.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 11/04/2022

... (1/6 no crime de associação para o tráfico e de 1/5 para o crime de tráfico de drogas), haja vista que fundamentada na multirreincidência do agravante (fl. 139). (...). (STJ, AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021, destaquei). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Vila Clementina - CEP 19802-300, Fone:

(18)3322-6011, Assis-SP - E-mail: assis3cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500389-95.2022.8.26.0047

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044429/2022 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 23051883 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 2044429 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-ASSIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANILO TIAGO DE BRITO

Vítima:

LUCAS POMPILO CUSTODIO MENDES

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

11/04/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 11 de abril de 2022, às 16h30, na sala de audiências virtual da 3ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Assis, Estado de São Paulo, sob a presidência do Excelentíssimo Senhor Doutor ARNALDO LUIZ ZASSO VALDERRAMA, Meritíssimo Juiz de Direito, acompanhado do Escrevente ao final nomeado, foi aberta a presente audiência nos autos da ação e entre as partes em epígrafe, realizada na modalidade de teleconferência, através de ferramenta disponível no Microsoft Teams. Apregoadas as partes, participaram o Excelentíssimo Senhor Doutor Fernando Fernandes Fraga, Promotor de Justiça, o réu Danilo Tiago de Brito, seu advogado, Dr. Vinícius Santana Vignotto. OAB/SP 421.014, e as testemunhas Ronaldo Viana da Silva e Gustavo de Melo Belloti. Ausente a vítima Lucas Pompilio Custódio Mendes. Iniciados os trabalhos, procedeu-se a oitiva das testemunhas, interrogatório do réu e apresentação de alegações finais orais pelas partes. Os depoimentos foram capturados pelo sistema audiovisual, na modalidade de teleconferência, nos termos

Comunicado CG Nº 284/2020, da Corregedoria Geral da Justiça, cujos arquivos são acessíveis por download, em link a ser disponibilizado, e gravada no CD encartado. Inclusive, feita a advertência que a gravação destina-se, exclusivamente, aos processos judiciais, desautorizada qualquer divulgação ou transmissão de sua imagem por qualquer meio, sob pena de apuração de responsabilidade civil e criminal. O Promotor de Justiça e o advogado do acusado desistiram da oitiva da(s) a vítima Lucas Pompílio Custódio Mendes, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida sentença: Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Danilo Tiago de Brito, qualificado nos autos, por ter, em tese, praticado o delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal. Narrou que na manhã de 16 de fevereiro de 2022, no interior da UPA situada na Rua Osmar Luchini, nº 670, Conjunto Habitacional Irmã Catarina, nesta cidade e Comarca, Danilo subtraiu para si um telefone celular Positivo, avaliado em R\$ 300,00, pertencente a Lucas Pompílio Custódio Mendes. Segundo apurado, a esposa do réu e a vítima estavam internados na UPA; aproveitando-se de que a vítima adormeceu pelo uso de medicamentos, Danilo apoderou-se do celular de Lucas e evadiu-se; ao perceber o desaparecimento do aparelho, Lucas conversou com funcionário da UPA e viram nas imagens do sistema de monitoramento as características do indivíduo; a polícia militar prendeu em flagrante do denunciado na posse do bem. A denúncia foi recebida em 02/03/2022 (fls.158/159). Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls.162/166). Nesta data foi feita a oitiva da vítima, testemunhas e o interrogatório do réu. Em alegações finais orais o douto membro do Ministério Público solicitou a condenação do réu, sob os argumentos de que a prova oral indica que o celular furtado estava na posse do réu e foi reconhecido pela vítima; não há indicativo de que os policiais tenham mentido para prejudicar o acusado; o réu não apresentou justificativa plausível para a posse do aparelho; devem ser reconhecidos os maus antecedentes do réu e o fato de ter praticado o crime enquanto gozava do livramento condicional; o réu é reincidente e praticou o crime durante período de pandemia; deve ser fixado o regime inicial fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A douda Defesa solicitou a absolvição do réu. Sustentou que o réu negou o crime e estava cuidando de sua esposa na delegacia; as provas são frágeis para condenação; deveriam as imagens do sistema de monitoramento interno ter sido juntadas aos autos; o réu falou que os policiais possuem rusga com relação a ele; no caso de condenação deve a pena ser fixada no mínimo legal e ser aplicada a atenuante do art. 16, pelo aparelho ter sido restituído; não deve ser aplicada a agravante do crime durante a pandemia. É o relatório. Fundamento e decido. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação é procedente. A materialidade do furto foi provada pelo auto de prisão em flagrante (fl.01), boletim de ocorrência (fls.07/09) e auto de exibição e apreensão (fl.11). A prova oral colhida sob o crivo do contraditório corroborou a autoria atribuída ao acusado. Em seu interrogatório Danilo negou o crime. Afirmou que ao ser abordado estava em frente ao Material de Construção Mazetto, sua esposa estava internada na UPA. Relatou que os policiais falaram que tinha filmagem do furto e em nenhum momento pegaram o aparelho em seu nome. Negou ter dito a eles que o telefone era de sua esposa. Mencionou que quando precisou usar o telefone usou o da recepção. Declarou que em outra ocasião os policiais Ronaldo e Gustavo já lhe abordaram e agrediram sem motivo. Narrou que o Delegado lhe mostrou aparelho todo quebrado. Negou que os policiais tenham mostrado as filmagens. Disse que foi condenado por furto e cumpriu 14 anos, quando saiu da cadeia tinha carteira assinada, depois ficou desempregado. A testemunha Gustavo afirmou que foi acionada para atender a um furto de celular, da vítima Lucas. Relatou que se deparou com o réu, era conhecido por vários furtos, abordou-o antes de chegar ao hospital. Mencionou que o celular estava com o réu e ele falou que era da esposa. Declarou que estavam a três ou quatro quadras mostrou o celular ao Lucas, ele reconheceu como dele. Salientou que mostraram uma foto do réu e a vítima contou que o réu estava na UPA com a esposa. Declarou que a vítima falou que estava lá para tratar de uma doença, ingeriu medicamentos e dormiu, ao acordar o celular que estava carregando tinha sumido. Contou que a vítima reconheceu o réu e disse ter conversado com ele. Tais

informações foram confirmadas pelo policial Gustavo. Declarou que a vítima reconheceu o aparelho e que o réu era conhecido por furto. Negou ter procurado as imagens da câmera de segurança porque o réu foi abordado nas proximidades da UPA com o aparelho. A vítima Lucas, ouvido na Delegacia de Polícia, afirmou (fl.04) que está internado na UPA de Assis, tomou medicamento, dormiu e ao acordar seu celular havia sumido. Relatou que ao visualizar as imagens da câmera de segurança viram as características de indivíduo suspeito. Mencionou que passaram as informações à polícia e localizaram o indivíduo na posse de seu celular. Negou ter visto o momento do furto porque dormia. Pois bem. Queda-se remansosa a inexistência de qualquer ato de disposição por parte da vítima que legitimasse a posse do celular pelo acusado. A inexistência de autorização do proprietário torna certo que ela estava a possuir "coisa alheia móvel", elemento essencial do tipo penal e, por isso, detinha pleno conhecimento da ilicitude de sua conduta. A palavra da vítima, porque protagonista do fato delituoso, não pode ser recebido geralmente com reservas, senão como expressão da verdade, que só a prova do erro ou da má-fé pode abalar, a qual não se encontra presente no caso em tela. Os policiais hoje inquiridos falaram que a vítima comunicou a ocorrência de furto de celular, nas imediações da UPA avistou o acusado e como é pessoa conhecida nos meios policiais por furto fizeram a abordagem, na posse dele encontraram a res furtiva. Falaram que ele disse que o aparelho era da esposa, mas a vítima reconheceu como sendo dele e comprovou isso por meio das fotos que estavam no aparelho. Vê-se que a apreensão do produto de furto em poder do requerido assume significativa eficácia probatória no sentido da legitimidade da acusação, visto que, até prova em contrário, gera presunção de responsabilidade criminal. Nesse sentido, cite-se o julgado: "Furto - Apreensão do bem subtraído com o réu - Presunção de autoria - Configuração - A apreensão da res furtiva, quando aliada a outras provas, mesmo indiciárias, leva à presunção de ser o seu possuidor o autor do furto, devendo este justificar e comprovar devidamente, em inversão probatória, a legitimidade da posse". (TJSP; Apelação nº 1389183/2; Órgão: 12º Câmara Criminal; Relator (a): Des. Luis Ganzerla; Julgamento: 03/11/2003). Com efeito, em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à defesa demonstrar posse de boa-fé. Nada sendo produzida, a presunção transforma-se em certeza de autoria, visto o ônus de produzir prova contrária ao que normalmente ocorre, conforme arts. 156 e 189, do Código de Processo Penal. No caso o réu limitou-se a sustentar que os policiais estão mentindo, que sofre perseguição e que falaram que iam lhe mostrar as imagens da câmera de segurança. Todavia, não trouxe nenhuma prova da alegada perseguição policial. Além disso, nenhuma das partes requereu a vinda aos autos das imagens da câmera de segurança e esta prova é desnecessária diante da localização da res furtiva na posse do réu, logo após a prática do furto. Não há motivo para duvidar da palavra dos policiais. Ressalto que os depoimentos dos policiais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas que teriam ensejado a prisão do réu. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais incumbidos do dever da repressão penal (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263). Na verdade, inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais ou guardas civis. Não há elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o réu e não se pode desmerecer a fala só por pertencerem aos quadros da Polícia. Foram submetidos ao contraditório como qualquer testemunha. Seria contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção da criminalidade e negar-lhe esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta de suas atividades. Guilherme de Souza Nucci leciona sobre a validade dos depoimentos dos policiais: "(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão

do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 2ª ed., São Paulo: RT, 2007, p.323). Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j.05.09.06 DJU 16.02.07, destaquei). "O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p.39.846, destaquei). Na mesma linha é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. [...]. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS OFENDIDOS. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA. [...] 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada. (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011, destaquei). HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, DA LEI N.º 11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. [...]" (STJ HC 149.540/SP 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.2011 DJU 04.05.2011, destaquei). "O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos". (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013, destaquei). No caso dos autos não se cogita que os policiais tenham localizado o celular na posse de um criminoso, deixando essa pessoa sair impune e tenham acusado o réu injustamente apenas para prejudicar uma pessoa que sabiam ser inocente. Não faz o menor sentido e esta tese não possui qualquer amparo na prova dos autos. Ultimada a instrução do feito, tenho que as provas se revelam impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória. Havendo prova

suficiente a comprovar a autoria e materialidade delitiva, presente a tipicidade da conduta perpetrada, a condenação do réu nas penas do crime de furto é medida que se impõe. Passo a dosar a pena, respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos arts. 59 e 60 do Código Penal, eis que em benefício do réu não milita quaisquer justificativa ou dirimente: A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta do réu, é elevadíssima, eis que o réu demonstrou falta de empatia e desprezo pela situação que a vítima passava, ao furtar uma pessoa internada para tratamento de saúde e que estava desacordada sob efeito de medicamentos. Considero tal elemento tão grave a ponto de justificar incremento da pena acima do patamar padrão de 1/6, o que vem sendo aceito pela jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE AFASTADA. REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. ORDEM JÁ PARCIALMENTE CONCEDIDA NESTA IMPETRAÇÃO. PENA-BASE E SEGUNDA FASE: QUANTUM DE PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - O entendimento deste eg. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). IV - Assente nesta eg. Corte que "não é possível mensurar, matematicamente, o aumento da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido" (AgRg no HC 309.253/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 8/3/2018)" (AgRg no REsp n. 1.529.699/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/6/2018). V - Ainda, verifica-se que a fixação da pena, na segunda fase da dosimetria, não se mostrou exacerbada (1/6 no crime de associação para o tráfico e de 1/5 para o crime de tráfico de drogas), haja vista que fundamentada na multirreincidência do agravante (fl. 139). (...) (STJ, AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021, destaquei). PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. APLICAÇÃO DO QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TERCEIRA FASE. INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES. AUMENTO DA PENA NA FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS). POSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) III - "A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto." (AgRg no REsp nº 1.430.71/AM, Sexta Turma, Relª Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 06.05.2015). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, e não pela incidência de circunstâncias judiciais constantes do art. 59 do Código Penal. (STJ, Habeas Corpus nº 520.193/RJ, 5ª Turma, Rel. Leopoldo de Arruda Raposo. j. 15.10.2019, DJe 21.10.2019, destaquei). "A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime" (STJ, AgRg no HC nº

188.873/AC, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em 08.10.2013, DJe de 16.10.2013, destaquei). O réu tem 18 reincidências, o que justifica usar uma delas a título de Maus Antecedentes. Segundo a doutrina, (...) "nada impede que o agente possua várias condenações anteriores, sendo lícito ao magistrado considerar uma delas para efeito de gerar reincidência e as demais, como Maus Antecedentes. Inexiste, nesta hipótese, bis in idem, pois são elementos geradores diversos". (Nucci, Guilherme de Souza, Individualização da pena, 6ª ed., rev.. atual e ampl., Rio de Janeiro, Forense, 2014, p.167). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça também adota entendimento de que "havendo mais de uma condenação com trânsito em julgado, não há ilegalidade ou bis in idem qualquer na consideração de condenações distintas para fins de Maus Antecedentes e de reincidência" (REsp n. 1.596.509/SC, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, julgado em 2/6/2016, DJe 14/6/2016, destaquei). A pena também merece ser majorada pela má conduta social, eis que pela folha de antecedentes o crime se deu enquanto o réu cumpria pena no regime aberto por outros crimes (há previsão de término de cumprimento da pena em 2029 e pela legislação extremamente leniente o réu estava solto). Destaco que "o fato de o agente ter cometido o crime enquanto usufruía do benefício da progressão de regime justifica a valoração negativa de sua conduta social" (STJ, AgRg no HC 556.444, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, 6ª Turma, j.18/08/2020). As circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo, não o prejudicando. As consequências não são desfavoráveis. Na primeira fase, após considerar tais elementos, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa. Na segunda fase ficou caracterizada a agravante da reincidência, prevista nos arts. 61, inc. I, e 63, ambos do Código Penal. Nesse aspecto, a doutrina estabelece que "o quantum da agravação depende do arbítrio do juiz, calçado nas circunstâncias do dado concreto e nos dados inerentes à pessoa do agente" (Damásio de Jesus, in Código Penal Anotado, 17ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2006, p.218). No caso concreto noto que o réu Danilo é multireincidente e apresenta inacreditáveis 18 condenações transitadas em julgado, inclusive várias por furto, e persistiu na senda do mesmo crime. O Supremo Tribunal Federal já admitiu a possibilidade de uma majoração rigorosa da pena em casos como este, pois tal prática demonstra certa profissionalização ou especialização da conduta criminosa. No final, o acórdão ficou ementado da seguinte forma: AGRADO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amalhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie. Precedentes. 2. Para justificar o percentual de 2/3 adotado para exacerbar a pena na segunda fase, as instâncias antecedentes destacaram "a multireincidência e a reincidência específica do recorrente, o qual ostenta 7 condenações anteriores" pelos crimes de roubo, furto, posse ilegal de arma e tráfico. A reincidência plúrima, nesse contexto, é circunstância idônea para o agravamento da pena, que se deu em patamar proporcional e adequado às particularidades do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado. 3. "Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas" (HC 118.079 - AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18.03.2014). 4. Agrado Regimental a que se nega provimento. (STF, Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 169738/SC, 1ª Turma, Rel. Alexandre de Moraes. j. 07.06.2019, maioria, DJe 14.06.2019). A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pelo maior aumento em razão da reincidência específica. Confira-se: "A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, e acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus. É permitido ao julgador mensurar com discricionariedade o quantum de aumento da pena a ser aplicado, desde que seja

observado o princípio do livre convencimento motivado. Na espécie, o julgado é claro em reconhecer a reincidência específica do paciente, fato que justifica o incremento da pena em 1/3 (STJ, HC nº 257.571/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18/02/2014)". Interessante notar pelo julgado acima citado que o patamar de 2/3 foi aceito pela Suprema Corte para uma pessoa que tinha 7 condenações, muito menos que o réu. Reconheço a agravante do art. 61, II, "j", do Código Penal, eis que o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Coronavírus, conforme reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20/03/2020, o que justifica incremento de 1/6 (um sexto). Entendo que há uma relação com o crime de furto, pois a pandemia refletiu no fluxo de pessoas e a própria vigilância policial. Esta agravante já foi aplicada em julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça: "(...) Impende destacar que os autuados foram presos em flagrante durante o período de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, circunstância que eleva a reprovabilidade de suas condutas, eis que previsto como agravante genérica (art. 61-II, 'j', do CP). Veja-se que nem mesmo o alto risco de contágio foi motivo suficiente a ser ponderado pelos indiciados a fim de dissuadi-los do intento deletério de cometerem os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Não se pode olvidar também que os averiguados descumpriram orientações do Ministério da Saúde de isolamento social, o qual está sendo amplamente divulgado nos meios de comunicação. Assim, as condutas dos autuados revestem-se de maior gravidade, eis que aumentaram os índices de disseminação do vírus COVID-19 a toda a população do Município, colocando em risco a saúde pública" (STJ, HC 584871/SP, Min. Nefi Cordeiro, j. em 04.06.2020, destaquei). Além disso, como bem destacou o Exmo. Des. Edison Brandão, "se trata de agravante de caráter objetivo, não se exigindo, portanto, requisito outro adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência" (TJSP, Apelação nº 1509419-67.2020.8.26.0228, 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26.01.2021). Somando as agravantes de 2/3 (dois terços) e 1/6 (um sexto), fixo a pena em 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa. Na terceira fase não há causas de diminuição de pena. É inviável reconhecer o arrependimento posterior previsto no art. 16 do Código Penal, eis que o réu não devolveu voluntariamente o aparelho, mas apenas após ser detido pelos policiais. Assim, torno definitivo o patamar de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face da renda apurada no interrogatório judicial, valor que deverá ser atualizado até o pagamento, segundo art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, do CP. Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime fechado, com esteio na alínea "b" do § 2º e § 3º, ambos do art. 33, do Código Penal, considerando que a reincidência e as circunstâncias do art. 59 do CP impedem o cumprimento inicial em regime mais brando. As diversas condenações demonstram que o réu faz de crimes patrimoniais seu meio de vida, o que justifica a imposição do regime mais gravoso. Nesse sentido, cite-se o julgado: STJ, Habeas Corpus nº 56850/SP, 5ª Turma, Rel. Gilson Dipp, j. 12.06.2006, DJ 01.08.2006. Dessa forma, incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em atenção ao art. 44, II, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, II, do CP, pelo motivo acima declinado. Por fim, foi publicada a Lei nº 12.736/2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal. Esta possui previsão legal no art. 42 do Código Penal, segundo o qual "computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior". Pelo art. 1º: "a detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condenatória, nos termos desta lei". Já o art. 2º acrescenta o § 2º ao art. 387: "o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Reputo a lei constitucional, por representar a vontade legítima do legislador de diminuir o tempo de espera para a progressão do regime e por competir ao legislador a tarefa de determinar o momento e juízo competente para

efetuar a detração. Considerando a pena acima fixada, o réu faria jus à progressão de regime ao semiaberto após o cumprimento de 1/5 da pena, o que não ocorreu. Assim, apesar da detração penal o regime ainda será o fechado. Diante do exposto, com fundamento no disposto no art.

387, do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE a pretensão veiculada nesta ação penal para: a) CONDENAR o réu Danilo Tiago de Brito, qualificado nos autos, à pena de 03 (três) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, cada qual no mínimo legal, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal; b) CONDENAR os réus ao pagamento das custas judiciais, previstas no art. 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, guardados os limites do art. 98, § 3º, do CPC, pois ficam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos porque não consta que a vítima tenha sofrido prejuízo. Uma vez que se cuida de réu que viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, é reincidente e ostenta maus antecedentes, tudo a indicar periculosidade, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e as jurisprudências que adoto como razão de decidir, in verbis: "Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHCnº111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013). "(...) Não se concede o direito ao apelo em liberdade a réu que permaneceu preso durante toda a instrução do processo, pois a manutenção na prisão constitui-se em um dos efeitos da respectiva condenação. Precedentes do STJ. A custódia provisória para recorrer não ofende a garantia da presunção da inocência. Incidência do verbete da Súmula n.º 09/STJ. Eventuais condições favoráveis do agente, como primariedade e bons antecedentes, não são garantidoras de direito subjetivo à liberdade provisória, se outros elementos dos autos recomendam a custódia preventiva. (...) " (STJ, RHC 18438/PR, 5ª Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 19.12.2005, p. 446, destaquei). Recomende-se o réu no local onde está detido, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional. Sentença registrada eletronicamente. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpram-se as Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo. Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Em observância ao item 22, "d", do Capítulo V das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD; 2) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 3) Extraia-se a guia de execução definitiva conforme art. 105 da Lei de Execução Penal; 4) Comunique-se ao ofendido do conteúdo desta decisão, ex vi do art. 201, § 2º, do CPP; 5) Expeça-se certidão de honorários ao douto Advogado nomeado; 6) Certifique-se o cálculo da pena de multa e/ou taxa judiciária, nos termos do Provimento C.G. nº 11/2015, disponibilizado no D.J.E. de 27/02/2015; 7) Após, intime(m)-se o(s) réu(s), via carta de intimação com AR, a fim de que pague(m) a multa (privativa/cumulativa) em favor do FUNPESP - Fundo Penitenciário do Estado de São Paulo - a ser feito no Banco do Brasil, Agência 1897-X, conta nº 139.521-1, comprovando-se nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de execução da pena pecuniária pelo Ministério Público; 8) Comprovado o pagamento da multa, certifique-se e comunique-se à VEC; 9) Se o(s) réu(s) não for(em) encontrado(s) ou não pagar(em) no prazo supra, certifique-se, extraia-se certidão de sentença e dê-se vista ao Ministério Público para ajuizar ação de execução junto à VEC. Lance-se a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal", a qual atribuíra ao processo a situação "suspense", e encaminhe-se o processo com tramitação digital, automaticamente, para a fila "Ag. Execução - Pena de Multa"; 10) Não havendo comunicação do ajuizamento da ação de execução da multa penal, e decorrido o lapso prescricional, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para extinguir a pena e determinar a remessa dos autos ao arquivo definitivo; 11) Com a

comunicação, pelo Juízo da execução, do ajuizamento da ação de execução da multa penal, anote-se no histórico de partes o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução; 12) Após, lance-se a movimentação "61619 - Definitivo - Processo Findo com Condenação" e arquivem-se os presentes autos; 13) Com a comunicação, pelo Juízo da Execução, da extinção da pena de multa, altere-se a situação do processo com o lançamento da movimentação "Cód. 22- Baixa Definitiva". Em seguida, o(a)(s) Defensor(a)(es) e o(s)rêu(s) manifestou(aram) o desejo de recorrer contra a sentença proferida nesta data. Pelo MM. Juiz foi decidido: Vistos. 1. Recebo o recurso interposto pelo(a) defensor(a). Sai o(a) Defensor(a) intimado(a) para apresentação das razões no prazo de 8 (oito) dias. 2. Se não forem apresentadas razões no prazo, intime o Advogado para apresentar as razões em 24 (vinte e quatro) horas. 3. Se não fizer, comunique o fato à OAB, nomeie outro Defensor e o intime para apresentar as razões recursais no prazo legal. 4. Expeça-se a certidão de honorários parciais à douda Defesa em 70% do respectivo item do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a OAB. 5. Após a expedição da certidão, intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões no prazo de 8 (oito) dias; 6. Expeça-se a guia de execução provisória e envie-se à VEC competente. 7. Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do recurso de apelação interposto pelo(s) sentenciado(s), observando-se as formalidades legais. Considerando a pena imposta, anoto que a prescrição da pretensão punitiva ocorrerá em 10 de abril de 2030. Saem os presentes intimados. Nada mais. Lido e achado conforme. Dispensada a assinatura dos presentes, nos termos do art. 1.269, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria da Justiça de São Paulo. Eu, Antônio Celso Sanches, digitei.